

1500728-49.2021.8.26.0545
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho
Comarca: Bragança Paulista
Foro: Foro de Bragança Paulista
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/04/2022
... Data de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bragança Paulista
Foro de Bragança Paulista
2ª Vara Criminal
Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500728-49.2021.8.26.0545
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2179418/2021 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 18848654 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2487/2021 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2179418 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 2487/21/929 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARCIANO APARECIDO PUGAS e outros
Réu Preso
Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

MARCIANO APARECIDO PUGAS, WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA e WILSON GARCIA ROMERO foram

denunciados como incursores nas sanções dos artigos 33 e 35, c.c. artigo 40, inciso III, todos da Lei 11.343/2006, porque no dia 02 de julho de 2021, na rua Voluntário Elias Bedran, 67, Jardim das Laranjeiras, nesta cidade e Comarca, nas imediações de um estabelecimento social, guardavam e tinham em depósito, 88 microtubos contendo cocaína, 02 papelotes de cocaína e 86 pedras de crack, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, associaram-se para a prática do tráfico ilícito de drogas.

Devidamente notificados, os acusados apresentaram defesas preliminares às fls. 338/339 e 359/360. Recebida a denúncia aos 28 de setembro de 2021 (fl. 363), deu-se a regular instrução do processo.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação e uma da defesa (fl. 400). Ao final, realizaram-se os interrogatórios dos acusados (fl. 400).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência parcial da ação, nos termos da denúncia e de seu aditamento, certa de que as provas colhidas estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 619/631).

As defesas postularam as absolvições embasadas na ausência de provas das autorias e na fragilidade dos depoimentos colhidos, além de combaterem a causa de aumento de pena denunciada (fls. 639/663 e 665/684).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito contra a saúde pública está plenamente comprovada.

Os laudos de exame químico toxicológico (fls. 268/276) descreveram e concluíram que as substâncias analisadas são cocaína, caracterizadas por meio de análises químicas e cromatográficas.

Por outro lado, as autorias não restaram comprovadas quanto aos coacusados Wellington e Wilson.

Wellington, assim como fizera na etapa policial, declarou que no dia dos fatos estava em sua casa quando ali chegou Marciano, pessoa a quem já conhecia por terem trabalhado anteriormente na mesma empresa. Contou que Marciano lhe pediu para guardar uma bolsa onde, segundo ele, havia roupas sujas e que retornaria posteriormente para pegá-la.

Mencionou que logo depois policiais militares chegaram e o indagaram se Marciano havia deixado alguma coisa consigo. De pronto, indicou a eles a bolsa que Marciano havia deixado no local, minutos antes. Disse, também, que os policiais militares revistaram a bolsa e localizaram em seu interior certa quantidade de drogas.

Ao final, argumentou que desconhecia a existência daquele entorpecente, bem como informou que não conhecia o coacusado Wilson.

Por sua vez, Wilson esclareceu que dias antes do ocorrido contatou o Marciano e o chamou para trabalhar consigo na construção civil. Então naquele dia combinou com Marciano de pegá-lo num imóvel situado na Vila Bianchi. Contou que quando chegou, Marciano lhe disse que iria guardar umas coisas numa casa e na sequência sairiam para trabalhar.

Depois disso, Marciano entrou em seu veículo e rumaram para o lugar onde iriam preparar um terreno para futura construção. Contudo, no trajeto, foram abordados por policiais militares que lhe informaram sobre uma suposta denúncia de tráfico de drogas.

Confirmou que de fato havia um caderno no interior de seu veículo, de propriedade de sua esposa, que utilizaria para apontamentos na obra, como posição de nível e marcações diversas. Defendeu-se dizendo que as anotações existentes no caderno, com nomes e valores, referiam-se a trabalhos anteriores por ele realizado e que não possuíam qualquer relação com o tráfico de drogas.

Finalizou dizendo que em momento algum entregou ao coacusado Wellington a bolsa onde foram encontradas as drogas, bem como afirmou que somente o conhecia de vista.

Suas versões não podem ser contrariadas com eficiência.

Isso porque os policiais ouvidos mencionaram de maneira uníssona que a droga apreendida durante a diligência se encontrava dentro de uma bolsa, de propriedade do coacusado Marciano.

O PM William narrou que naquele dia realizava patrulhamento de rotina quando foi abordado por uma pessoa que lhe confidenciou uma possível situação de tráfico de drogas. Segundo ela, um senhor de idade, na condução de um determinado veículo, estaria realizando a entrega de drogas na Vila Bianchi.

Diante disso, seguiu para o endereço informado e se deparou com um veículo que possuía as mesmas características indicadas pelo delator, momento em que observou que um homem, identificado posteriormente como sendo Marciano, saiu do interior daquele imóvel e adentrou no veículo, como passageiro. Observou, ainda, que o condutor possuía as mesmas características indicadas pelo solicitante, dentre elas, cabelos grisalhos.

Realizada a abordagem aos ocupantes do veículo, identificou o condutor como sendo o acusado Wilson, bem como seu passageiro, coacusado Marciano. Contudo, nada de ilícito foi localizado no veículo, apenas um caderno contendo anotações supostamente de tráfico de drogas, além de um aparelho celular.

Prosseguindo a diligência, retornou ao imóvel onde visualizara Marciano anteriormente. Lá se deparou com Wellington, morador no local, que lhe informou que Marciano havia deixado em sua casa uma bolsa contendo roupas. Salientou que a droga apreendida durante a diligência policial foi localizada dentro daquela bolsa. Pontue-se que o policial militar declarou que tanto Wellington como Marciano apresentaram a mesma versão, qual seja, de que a bolsa que continha a droga foi deixada no local pelo coacusado Marciano.

Vejamos um trecho de seu depoimento:

D: Eu me recordo do dia que uma senhora, ela falou pra gente que tinha um carro parado na referida via passada, e que o senhor estava entregando entorpecentes prontos pra comercialização. Passou as características do veículo, bem como seria o senhor né? Adentramos a via, deparamos com o veículo, porém ainda estava no contrafluxo nosso. Fizemos o contorno. Fomos atrás do veículo. Abordamos. Já na rua onde a gente se deparou com o veículo, o veículo estava saindo da casa um rapaz, posterior abordado, foi constatado como chamado Marciano o rapaz, salvo engano. Na direção do veículo estava um senhor, mais de cabelo grisalho, um senhor chamado Wilson, estava na direção do veículo. Foi abordado, com ele nada de ilícito foi encontrado. Porém foi localizado dentro do veículo um caderno com anotações pertinentes aí ao tráfico de entorpecentes, e o celular do senhor que estava dirigindo o veículo não parava, intensamente, chegando mensagem acerca de provavelmente acerca de tráfico de droga também. Voltamos à residência, da onde o Marciano tinha saído, fizemos contato com o Wellington, que é o terceiro indivíduo, que estava na residência, relatou pra gente que o rapaz tinha saído era amigo dele, tinha deixado uma bolsa com ele, que foi a versão que ele deu pra gente, com roupas. Dentro da bolsa, ele acompanhou a vistoria, foi localizado entorpecentes e 122 reais em dinheiro.

J.: Nenhum deles sabia de nada?

D.: Não. Falou que não sabia de nada. O único que confirmou, que bateu realmente ideia com a gente na entrevista pessoal foi o Wellington falou pra nós, e o Marciano falou que deixou a mochila com roupa. Realmente, tinha roupa, porém roupa e droga.

Def.: É, em relação ao Wellington, ele se mostrou em algum momento surpreso com a abordagem do senhor, ou ele também, ou ele colaborou?

D.: Não. Ele colaborou, ele atendeu a gente né, ele estava dentro da casa, ele atendeu a gente, a gente perguntou pra ele acerca do, se alguém deixou alguma coisa com ele, ele falou: "não, o rapaz, de nome Marciano, deixou a mochila comigo com roupas. Aí a gente verificou essa mochila, perguntamos se era aquela, aí ele falou assim que realmente tinha, falou: Ó a mochila está aqui".

Gize-se, ainda, que referido policial militar confirmou que dentro do veículo abordado havia diversas ferramentas de pedreiro, corroborando, destarte, com a versão trazida por Wilson de que quando foram abordados seguiam para uma obra onde

iria realizar serviços de construção civil.

No mesmo sentido foram as palavras da PM Dayane. Ela informou que somente chegaram ao local dos fatos após a informação de um transeunte. Declarou que a droga foi localizada numa mochila e que Wellington confirmou que ela pertencia a Marciano, bem como que ele havia deixado a bolsa no local minutos antes dos policiais chegarem na residência. Aduziu, ainda, que Marciano também confirmou que naquele dia deixou uma mochila contendo roupas sujas na casa de Wellington.

No que se refere à Wilson, a testemunha asseverou que durante a diligência ele confirmou que foi até o local somente para pegar Marciano para levá-lo até um terreno onde ambos iriam realizar a medição. Por fim, mencionou que no interior do veículo havia pedaços de bambus, cordas e equipamentos utilizados no serviço de construção civil.

Não obstante os policiais militares tenham salientado que durante a diligência policial apreenderam um caderno contendo anotações sobre o tráfico de drogas, visando, destarte, confirmar o envolvimento de Wilson na ação delituosa, analisando-se tais apontamentos, constantes nas cópias digitalizadas às fls. 404/420, conclui-se que as referências lá existentes com nomes e valores, por si só, não são suficientes para comprovar que de fato elas se referem a anotações de dívidas oriundas do tráfico de drogas.

A par disto, no laudo pericial realizado no celular pertencente a Wilson (fls. 491/524) não foram observadas mensagens ou conversas indicando o seu envolvimento com a venda ilícita de drogas.

Lado outro, a contribuir com a versão de Wilson, os policiais mencionaram que dentro do veículo havia ferramentas utilizadas no ramo da construção civil, além de corda e pedaços de bambu, corroborando com a alegação do acusado de que foi abordado pelos agentes públicos quando se dirigia para um terreno, local em que pretendia realizar a sua medição para futura construção.

Ademais, também é unânime pelos depoimentos colhidos nos autos, assim como pelas versões trazidas pelos acusados, de que a bolsa/mochila em que foi encontrada a droga pertencia a Marciano e que fora por ele deixada na casa de Wellington. Gize-se que, quando interrogado, Marciano confirmou que possuía uma mochila contendo roupa de serviço, embora tenha argumentado que a havia deixado no interior do veículo.

Por fim, deve-se acrescentar que a suposta delatora que indicou o tráfico de drogas no local em que os acusados foram capturados sequer foi identificada, tampouco compareceu em Juízo para ratificar sua suspeita.

Creemos, assim, ser insuficiente uma única denúncia, ainda que amparada pelas palavras dos policiais militares.

Muito embora este Juízo tenha entendimento de que as denúncias anônimas se traduzem em fortes elementos de convicção para o julgador, elas devem vir cercadas de outros elementos que lhe deem credibilidade, o que não aconteceu na espécie.

Por simples e únicas denúncias, antes dos fatos, os agentes públicos entenderam que os delatados seriam os acusados.

Contudo, com eles não foi apreendida quantidade relevante de dinheiro com origem ilícita ou qualquer outro objeto capaz de ensejar a traficância. Gize-se, ainda, que os policiais disseram que não conheciam os acusados de outras ocorrências. Uma condenação baseada unicamente em informação apócrifa seria contrária à ordem jurídica constitucional, que veda expressamente o anonimato. O acolhimento de delação anônima sem outra prova que a ampare permitiria a prática do denunciismo inescrupuloso, voltado a prejudicar desafortunados, o que violaria o inciso IV do artigo 5º da CF ("IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato"). Sobre a questão já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A delação apócrifa não constitui elemento de prova sobre a autoria delitiva, ainda que indiciária; é mera notícia vinda de pessoa sem nenhum compromisso com a veracidade do conteúdo de suas informações, haja vista que a falta de identificação inviabiliza, inclusive, a sua responsabilização pela prática de denúncia caluniosa (artigo 339 do CP). (STJ - HC nº 64.096 - PR - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - J. 27.05.2008).

Destarte, inexistem nos autos provas seguras do envolvimento de Wilson e Wellington com a droga apreendida.

Eles também não foram capturados em situação que levasse a crer que atuavam em parceria com Marciano ou que seriam eles os donos do material apreendido no local. Portanto, não há nenhuma prova ou elemento que indique que Wilson e Wellington também seriam os proprietários da droga e que a substância estaria destinada por eles à comercialização ou entrega a terceiros. Na dúvida, deve-se aceitar a versão dos acusados.

Desta forma, percebe-se que a prova colhida é demais frágil para sustentar uma condenação por tráfico de entorpecentes.

Não é possível condenar alguém com base apenas numa dedução, ou num mero juízo de probabilidade, assim como não é possível segregar uma pessoa por fundamento apenas suposição de que a droga pudesse ser deles, sobretudo considerando-se a gravidade da pena prevista e o rigor da lei no que se refere à sua execução.

Nada liga a droga a eles com segurança, como ainda estão ausentes nos autos quaisquer circunstâncias que pudessem ensejar a participação deles no tráfico de entorpecentes.

A condenação de agentes como incurso nas sanções previstas para o crime de tráfico de entorpecentes requer prova segura, de modo que, restando dúvidas quanto à autoria quando encerrada a instrução processual, é de se impor a absolvição, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", consagrado no artigo 386, VII, CPP. Por outro lado, no tocante a Marciano, a autoria é segura, não obstante em seu interrogatório tenha negado a prática da infração, argumentando que não seria proprietário das drogas localizadas no interior de uma mochila.

Os policiais militares William e Dayane narraram que após chegarem na casa de Wellington ele lhes entregou uma mochila lá deixada por Marciano. Realizada revista, apreenderam em seu interior diversas porções de droga, além de uma quantia em dinheiro.

Salientaram, ainda, que Marciano lhes confirmou que de fato havia deixado uma mochila na casa de Wellington.

Vejamos um trecho do depoimento da PM Dayane:

Def.: Em relação ao Marciano, a senhora, é, na verdade, só havia a imputação feita pelo Wellington, a senhora não conseguiu encontrar nada de ilícito na posse do Marciano?

D.: Com ele não tinha nada. Ele falou que tinha deixado a mochila no Wellington, então o Wellington confirmou que a mochila estava lá, e na mochila foi localizado entorpecente.

Def.: Tá, mas o Marciano...

D.: Que o Marciano fala que é dele e o Wellington fala que ele deixou lá.

Def.: O Marciano chegou a afirmar que deixou uma mochila com o Wellington?

D.: Sim. "Eu deixei uma mochila na casa do Wellington". Foi por isso que eu cheguei na casa, foi conversado com o senhor Wellington, ele confirmou que o Marciano deixou a mochila lá. Foi vistoriada a mochila e foi localizada a droga.

Nada existe nos autos a demonstrar que os policiais militares responsáveis pela prisão do acusado tivessem qualquer motivo para imputar a ele, indevidamente, a prática de crime, em especial da gravidade do denunciado. Por seus conteúdos, eles são suficientes a comprovar a situação de traficância.

Por isso mesmo, a intenção de comerciar fica consubstanciada visto que tais provas apontam claramente para esta finalidade do agente. Não há nada que possa desabonar o depoimento dos policiais envolvidos, pois seus atos presumem-se legítimos por força de princípio administrativo.

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito".

Destarte, o argumento de que seus depoimentos estariam comprometidos pelo fato de

terem o dever legal de justificar sua atividade não pode ser aceito. Se o fosse, estaria estabelecido preconceito odioso em relação a pessoas que auxiliam a justiça na busca da verdade real.

Assim, seus depoimentos são analisados e cotejados com os demais elementos carreados aos autos, sem maior ou menor relevância pelo fato de serem agentes de segurança do Estado, responsáveis pela repressão ao crime.

Neste diapasão, tem se manifestado a jurisprudência ao tratar do depoimento policial. Veja-se:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese dos desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito" (Tacrím/SP - JUTACRIM 30/221).

Repise-se, assim, que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são harmônicos e uníssonos. Frisa-se também que ambos agentes públicos em seus depoimentos esclareceram, sem nenhuma contradição entre eles, o ocorrido naquela ocasião, inclusive com riquezas de detalhes demonstrando toda a operação realizada desde a chegada ao local e a apreensão das drogas, assim como as versões apresentadas pelos acusados durante suas prisões, não havendo, em princípio, nada que desabone esses depoimentos.

Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROCESSO PENAL - PROVA -DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - IDONEIDADE -RECONHECIMENTO. É idônea a prova testemunhai colhida, constituída do depoimento dos policiais que efetuaram a diligência. (TJ-SP - APL: 993061147033 SP, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 04/05/2010, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2010)

APELAÇÃO. INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRELIMINAR AFASTADA. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito. Tendo em vista que os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito têm natureza de "crimes permanentes", admite-se a prisão em flagrante sempre, ainda que esta prisão seja realizada no interior de uma residência. Precedentes do STF. 2. As autorias e as materialidades dos crimes de tráfico de drogas e roubos, um majorado e outro simples, restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas na casa do réu e os objetos roubados encontrados em sua posse. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 12. O instituto da detração, para ser aplicado, depende da análise da situação processual do sentenciado, inclusive no que concerne a eventuais condenações e unificação de penas. Portanto, o Juízo das Execuções Penais é a sede mais adequada para a apreciação da matéria. 13. Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00628017920128260050 SP 0062801-79.2012.8.26.0050,

Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância entorpecente foi encontrada na posse de um dos réus, como também porque restou comprovado o vínculo associativo entre ambos os dois para fins da prática, reiterada ou não, do comércio espúrio, mercê de provas idôneas e suficientes para as suas responsabilizações. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o crime. 3. Dosimetria da pena fixada de modo escorreito. 4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, órgão constitucionalmente competente para tanto. Ademais, "in casu", o regime fixado continua sendo o fechado, mercê da pena imposta aos réus, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 5. Improvimento dos recursos das defesas. (TJ-SP - APL: 00015180220118260370 SP 0001518-02.2011.8.26.0370, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 14/04/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/04/2014) Não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as provas orais colhidas.

A finalidade de traficar está bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga encontrada, em porções prontas para a venda, a variedade de espécies e as circunstâncias como foi surpreendido, tudo indica para uma guarda com a intenção de tráfico, venda.

O crime de tráfico ilícito de drogas traz em seu tipo penal vários verbos que exprimem as formas de conduta puníveis, algumas de natureza instantânea, outras permanentes, não sendo necessário para sua configuração tenha o agente efetuado a venda. Basta que a possua ou tenha em depósito com o fim de colocá-la em circulação, incorrendo, assim, em uma das figuras do tipo.

Em escólio à norma em apreço, o renomado VICENTE GRECO FILHO leciona a respeito da prescindibilidade da ocorrência da venda do produto, assim asseverando:

"Para a existência do delito não há necessidade de ocorrência do dano. O próprio perigo é presumido em caráter absoluto, bastando para a configuração do crime que a conduta seja subsumida num dos verbos previstos" (Tóxicos - Prevenção - Repressão. Saraiva, 1987, p. 81.)

A esse respeito, esclarecedor é o seguinte julgado:

"Para a consumação do delito de comércio clandestino de entorpecente, não importa que o produto não tenha sido distribuído à venda. Consuma-se ele embora não tenha resultado o dano. Seu não-exaurimento, porém, é irrelevante, vez que não, ficou afastada a real periclitación do bem jurídico penalmente protegido. Nem se há de falar na hipótese de crime impossível." (RT 401/75)

Nas modalidades que configuram crime permanente, ou seja, expor a venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, etc... evidenciado o início da execução, tem-se o crime por consumado.

A propósito, os ensinamentos do ilustre doutrinador MENA BARRETO, que bem demonstram o entendimento pacífico sobre a matéria:

"Afim, cabe nesta oportunidade lembrar, igualmente, algumas ações delituosas que têm caráter formal ou de consumação antecipada e que por via de consequência, dada a sua não-fragmentação, desautorizam a aceitação de tentativa. É o caso, *verbi gratia*, das relativas à guarda, ao depósito ou ao transporte de tóxicos, além da simples posse (trazer consigo)" (Lei de Tóxicos, Comentários por Artigo. Freitas Bastos, 1996, p. 74.).

Ora, a conduta praticada pelo acusado amolda-se perfeitamente à figura "guardar", prevista no tipo penal do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

No mais, a apreensão de apreciável quantidade de substância entorpecente, conduz à segura conclusão de estar configurado o delito de tráfico. Inadmissível eventual pedido de desclassificação do delito imputado quando ausente a prova da exclusividade de uso próprio, sendo da defesa e não da acusação o ônus da prova cabal e irrefutável da alegação de ser usuário e dependente, mesmo porque a condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário de droga.

Sobre a matéria:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida desclassificação para uso próprio. Descabimento. 1. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para a entrega e consumo de terceiros, drogas, consistentes em 21 (vinte e uma) porções de "Cannabis Sativa L.", popularmente conhecida como maconha e possuía e mantinha sob sua guarda 12 (doze) munições, calibre 22, uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e natureza da droga apreendida, e as circunstâncias de sua apreensão, afastam a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. (TJ-SP - APL: 00008425720168260474 SP 0000842-57.2016.8.26.0474, Relator: Alcides MalossiJunior, Data de Julgamento: 14/02/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2019).

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida desclassificação para uso próprio, ou, subsidiariamente, afastamento da reincidência, mitigação da pena, com aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, abrandamento do regime prisional para o início de cumprimento de pena e detração penal. Descabimento. 1. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado colocar algo em sua boca em atitude suspeita, justificando sua abordagem. Realizada busca pessoal, RENAN cuspiu do interior de sua boca oito pedras de crack envoltas em papel alumínio. Ato contínuo, dando continuidade à busca, os milicianos encontraram em poder do acusado, mais especificamente no interior de suas vestes íntimas, trinta e quatro porções de maconha, todas acondicionadas separadamente em sacos plásticos. Ainda, no interior dos bolsos da bermuda que o denunciado vestia, os policiais apreenderam um celular Motorola e a quantia de R\$ 68,00 em espécie. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e natureza da droga apreendida, afasta a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. 2. Dosimetria. A) Decisão bem fundamentada nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. B) Acusado reincidente específico que justifica o aumento adequado e proporcional aplicado pelo duto sentenciante, na segunda etapa da dosimetria da pena. C) Aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. Acusado reincidente, sendo suficiente a reincidência para a negativa da diminuição. Presença de elementos que demonstram que o réu se dedicava às atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas, indicando habitualidade. Impedimento do benefício. 3. Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente - Artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei nº 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5º, XLIII, da Constituição Federal e 33, § 3º, do Código Penal. 4. Detração Penal. Irrelevante, no caso, o

quantum da sanção para sua definição (regime), surge inaplicável a detração, para tanto, prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Eventual progressão, por outro lado, deverá ser avaliada no Juízo das Execuções, competente para tanto (artigo 66, III, b, LEP). Negado provimento. (TJ-SP - APR: 00005459420188260566 SP 0000545-94.2018.8.26.0566, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 23/05/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/05/2019).

Assim sendo, os argumentos defensivos ficam sem guarida nenhuma.

Não obstante os argumentos já expendidos em relação ao crime de tráfico, não deve prosperar a imputação de associação para tal finalidade.

Isto porque Marciano nada admitiu neste particular. Nenhum vestígio existe a respeito de uma eventual associação duradoura e estável. Os policiais nada relataram sobre a associação imputada.

O crime de associação se distingue do concurso eventual de pessoas que exige um acordo de vontades ocasional e efêmero para a perpetração de determinado crime; a associação pressupõe ajuste permanente ou estável para a perpetração de vários crimes de tráfico de entorpecentes (mínimo dois).

Na espécie não se vislumbrou a ocorrência de outros crimes de tráfico, como ainda, uma estabilidade na relação dos acusados, ainda mais se levarmos em conta a absolvição dos coacusados Wellington e Wilson.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes recomendam exacerbação, conforme indicam as certidões de fls. 604 e 606/607. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não são diferenciados a ponto de justificarem maior reprovabilidade.

Presente a circunstância judicial acima exposta, que deve levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa, no patamar mínimo legal.

Na segunda fase, certificada a reincidência do agente à fl. 605, não utilizada para efeitos de maus antecedentes, suas penas serão elevadas em 1/6, não havendo outras atenuantes ou agravantes a considerar ($6 \text{ anos} + 1/6 = 7 \text{ anos}/600 \text{ dias} + 1/6 = 700 \text{ dias-multa}$).

Na etapa derradeira, não deve ser reconhecida a causa especial de aumento denunciada, prevista no artigo 40, inciso III.

O laudo anexo (fls. 343/345) apontou que o lugar do crime dista cerca de 321 metros do Lar de Idosos e 104 metros da Comunidade Assistencial CASJB. A lei não especificou distância para aplicação da majorante, trazendo expressão que depende de interpretação, qual seja, nas imediações de....

As distâncias referidas não podem ser consideradas compatíveis com o termo imediações, que tem significado de redondezas, arredores, vizinhanças ou proximidades. Isto porque se exige uma caminhada considerável para alcançar tal distância, além de estar comprometido o contato visual de qualquer pessoa normal, na maioria dos casos, como na espécie.

A par disto, a prova dos autos não demonstrou uma efetiva influência do tráfico exercido pelo agente neste local.

Logo, a proteção legal visando coibir o tráfico próximo às instituições em debate não deve operar na espécie.

O acusado é reincidente e portador de maus antecedentes, razão pela qual não se amolda na hipótese da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

O crime de tráfico foi equiparado, legalmente, aos hediondos, motivo pelo qual, em relação a ele, o condenado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade, mesmo porque a reincidência impede a substituição. Também compartilho do entendimento de que o crime de tráfico de drogas é a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as

famílias envolvidas, de modo que a concessão de regime menos gravoso ou mesmo de qualquer outro benefício, como a substituição da pena ou mesmo do sursis, além de ser incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou mesmo reprovação da prática delitativa, gerando ofensa ao disposto no artigo 44, III, do Código Penal, além de verdadeira sensação de impunidade. Por conta dos mesmos fundamentos o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, pois é o que melhor se amolda para início do cumprimento da pena por crime tão grave e atroz contra a saúde pública. Qualquer outro regime prisional não se coaduna com o tráfico, diante de tantas mazelas que sabidamente a droga provoca.

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese. Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo: 20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014).

O sentenciado não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/2014).

Saliente-se, ainda, que mesmo diante da atual circunstância, a par da recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que sugere a adoção de algumas providências pelos magistrados a fim de resguardar a saúde dos presos em face da pandemia gerada pelo Coronavírus, ela não o vincula, assim como não justifica por si só o pedido da defesa para conceder ao acusado o direito de apelar em liberdade com consequente liberdade provisória.

Deve se destacar que a Secretaria de Administração Penitenciária adotou medidas criteriosas para combate à pandemia nas unidades prisionais, como a suspensão de visitas, higienização das celas, triagem dos reeducandos em grupo de risco, imediato isolamento dos casos suspeitos etc. ; não bastasse, o atendimento hospitalar ao preso com suspeita de contaminação é imediato e, em muitos casos, inclusive mais célere do que aquele ofertado à população, em face da atual situação da malha hospitalar pública segundo registrado reiteradamente na imprensa. Infelizmente, todos os cidadãos do mundo estão expostos ao problema.

No mesmo sentido, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"...Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões

cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco..." (STJ AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

E mais:

HABEAS CORPUS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO REGIME E À PENA FIXADOS NA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO - Insurgência contra decisão mantida por esta C. Câmara Criminal, que, em razão disso, se coloca na posição de autoridade coatora - PRETENDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - Inexiste constrangimento ilegal em decisão que denega o direito de recorrer em liberdade, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" NÃO FORMULADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - Necessária a análise do pedido de prisão domiciliar pelo Juízo das Execuções, sob pena de supressão de instância. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2055190-16.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)

Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes e uso de distintivo ou uniforme de função pública que não exerce - Sentença condenatória, com fixação do regime inicial fechado e denegação do direito de recorrer em liberdade - Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal - Decisão fundamentada relativamente à dosimetria penal e quanto à manutenção dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva - Periculum libertatis que não se mitiga, por si só, pela eclosão da pandemia de Covid-19 - Ausência de demonstração, ademais, da existência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico, a justificar o conhecimento excepcional da postulação - Precedentes - Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada - Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2081034-65.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)

ENTORPECENTES. TRÁFICO (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inviabilidade. Questões que devem ser discutidas no recurso de apelação já interposto pela Defesa. Deferimento ao paciente do direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Estando presentes os requisitos da custódia cautelar durante a tramitação do feito, não tem sentido que se defira ao paciente a liberdade após o reconhecimento da responsabilidade de ambos por delito grave. Inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência. Súmula nº 09, do C. Superior Tribunal de Justiça. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2091866-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de:

a) ABSOLVER MARCIANO APARECIDO PUGAS, qualificado nos autos, da imputação do artigo 35, "caput", da Lei 11.343/2006, que lhe foi feita, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal;

b) ABSOLVER WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA e WILSON GARCIA ROMERO, qualificados nos autos, das imputações dos artigos 33 e 35, c.c. artigo 40, inciso III, todos da Lei 11.343/2006, que lhes foram feitas, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal;

c) CONDENAR MARCIANO APARECIDO PUGAS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e mais 700 (setecentos) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua situação econômica.

Ante a sentença absolutória, expeça-se alvará de soltura em favor de Wellington Oliveira da Silva, com urgência.

Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 723857/SP (fl. 539), a absolvição reconhecida ao paciente Wilson Garcia Romero. Por outro lado, haja vista à condenação de Marciano, recomende-se na prisão onde estiver.

Concedo a ele os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos, derivados do comércio ilícito de drogas, em virtude dos fundamentos utilizados nesta decisão, a teor do artigo 62, da Lei 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e providencie-se o necessário ao cumprimento da pena.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Bragança Paulista, 08 de abril de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA